

1501418-23.2021.8.26.0628

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: RAFAEL RAUCH

Comarca: Itapevi

Foro: Foro de Itapevi

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/10/2022

... não afasta a hediondez do crime de tráfico de drogas".

Foram, outrossim, compiladas as seguintes teses sobre o tema, na edição n.º 131 da Jurisprudência em Teses do C. STJ:

21) O tráfico ilícito de drogas na sua forma privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) não é crime equiparado a hediondo. (Tese revisada sob o rito do art. 1.036 do CPC/2015 - TEMA 600)

22) A ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapevi

Foro de Itapevi

Vara Criminal

Rua Vereador Dr. Cid Manoel de Oliveira, 405, Itapevi-SP - cep 06660-280

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501418-23.2021.8.26.0628 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501418-23.2021.8.26.0628

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2196132/2021 - DEL.POL.ITAPEVI, 19148514 - DEL.POL.ITAPEVI, 1952/21/407 - DEL.POL.ITAPEVI, 2196132 -

DEL.POL.ITAPEVI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JEAN LEANDRO MOREIRA DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RAFAEL RAUCH

Vistos.

JEAN LEANDRO MOREIRA DA SILVA, qualificado nos autos da Ação Penal em epígrafe que lhe move a Justiça Pública, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, combinado com o art. 40, III, ambos da Lei n.º 11.343/06.

Isso porque, no dia 20 de julho de 2021, por volta das 16h55min, na Rua Magali Wessel, altura do n.º 263, Jardim Itacolomi, nesta cidade e Comarca de Itapevi, o réu, próximo a uma escola, trazia consigo e vendia drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em audiência de custódia, o réu recebeu o benefício da liberdade provisória (f. 40-45). Na sequência, o acusado não foi mais localizado para notificação (f. 76), e o

Ministério Público requereu a decretação de sua prisão preventiva (f. 83-84), o que restou deferido por este Juízo (f. 85-86).

O réu foi preso (f. 94-97), notificado (f. 103) e apresentou defesa prévia (f. 107-108).

Não sendo caso de rejeição da denúncia ou de absolvição sumária, a exordial acusatória foi recebida por decisão datada de 25 de agosto de 2022, na qual também restou indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa (f. 109-110).

O réu foi citado, dando-se seguimento à persecução penal em Juízo.

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas, tendo-se interrogado o réu ao final (f. 132). Na sequência, encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais (f. 130-131).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

DECIDO.

Trata-se de ação penal na qual o Ministério Público imputa ao acusado a prática da infração penal prevista no art. 33, caput, combinado com o art. 40, III, ambos da Lei n.º 11.343/06.

Não havendo questões de admissibilidade a serem analisadas e, no mais, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao exame do mérito.

A pretensão acusatória é procedente.

A materialidade do delito está comprovada pelo auto de exibição e apreensão de f. 13-14, que atesta terem sido apreendidos os entorpecentes em posse do acusado, bem como a quantia de R\$ 78,50 em dinheiro.

As substâncias entorpecentes foram submetidas a exame pericial (f. 127-129), sendo que o resultado foi positivo para "crack", "cocaína" e "maconha", drogas de uso proscrito no Brasil.

O réu, em seu interrogatório, confessou a prática dos fatos narrados na exordial acusatória.

A confissão, aliás, restou corroborada pelos demais elementos probatórios coligidos aos autos.

Deveras, os guardas civis municipais, ouvidos sob o crivo do contraditório, foram contestes nos pontos essenciais e confirmaram a ocorrência dos fatos descritos na denúncia. Relatam que estavam em patrulhamento de rotina em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, quando receberam uma denúncia de populares de que havia alguém nas imediações traficando drogas. Dirigiram-se até o local indicado e, lá, avistaram o acusado dispensando uma sacola preta e tentando empreender fuga assim que viu a viatura. Perseguiram-no e abordaram-no. Em sua posse havia uma quantia em dinheiro e um aparelho de telefone celular. Na sacola dispensada pelo réu havia porções de drogas.

E nada há nos autos que indique eventual intenção espúria dos guardas civis municipais de incriminar injustamente o acusado. Assim, seus depoimentos merecem credibilidade e são valiosos para a condenação. Entendimento contrário acarretaria a ruína do sistema de segurança pública do Estado.

Frise-se, nesse passo, que as circunstâncias da abordagem, noticiadas nos depoimentos dos guardas, permitem presumir que as drogas apreendidas com o acusado se destinavam ao tráfico, não havendo espaço para eventual desclassificação da conduta praticada.

As provas, portanto, são bastantes para a condenação.

No que tange à causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei n.º 11.343/2006, imperativa a sua incidência. Observe-se.

Segundo os depoimentos dos guardas civis municipais ouvidos em juízo, sob o crivo do contraditório, o réu foi preso na rua de uma escola, a qual estava em funcionamento. Uma das testemunhas, aliás, ressaltou que o popular que os avisou sobre o tráfico foi uma pessoa que estava buscando uma criança da escola.

Frise-se que o delito foi praticado em julho de 2021, quando a pandemia causada pela Covid-19 já estava arrefecida, e os estabelecimentos de ensino, retornando ao seu normal funcionamento. Ademais, o delito foi praticado às 16h55min - horário em que os alunos estão estudando, como é de conhecimento geral.

E a finalidade da majorante é punir com maior rigor aqueles que se utilizam da aglomeração típica existente nas imediações de estabelecimentos de ensino para facilitar e ampliar a comercialização das drogas.

Confira-se, aliás, o enunciado n.º 41 da edição n.º 131 da Jurisprudência em Teses do C. STJ, que assim dispõe: “A incidência da majorante prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006 deve ser excepcionalmente afastada na hipótese de não existir nenhuma indicação de que houve o aproveitamento da aglomeração de pessoas ou a exposição dos frequentadores do local para a disseminação de drogas, verificando-se, caso a caso, as condições de dia, local e horário da prática do delito”.

No caso concreto, a hipótese excepcional não está comprovada, uma vez que o réu foi preso em flagrante na rua de uma escola, em dia e horário típicos da aglomeração existente nos locais previstos no art. 40, III, da Lei n.º 11.343/2006.

Nesse prisma, suficientemente configurada a incidência da causa de aumento em tela. No que tange à aplicação da causa de diminuição de pena, prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006, atento aos recentes julgados dos tribunais superiores sobre o assunto, revejo posicionamento anterior e passo a não vislumbrar inconstitucionalidade na incidência deste privilégio.

Explica-se.

A Terceira Seção do C. STJ, embora não tenha se pronunciado diretamente sobre a inconstitucionalidade ou não da causa especial de diminuição de pena em tela, ao revisar o REsp n.º 1.329.088/RS, afetado para julgamento pelo rito dos recursos repetitivos (arts. 1.036 e seguintes do CPC), no Tema n.º 600, firmou a seguinte tese: “O tráfico ilícito de drogas na sua forma privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) não é crime equiparado a hediondo”.

Com a revisão da tese anterior, o tribunal superior cancelou seu enunciado de súmula n.º 512, que assim dispunha: “A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 não afasta a hediondez do crime de tráfico de drogas”.

Foram, outrossim, compiladas as seguintes teses sobre o tema, na edição n.º 131 da Jurisprudência em Teses do C. STJ:

21) O tráfico ilícito de drogas na sua forma privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) não é crime equiparado a hediondo. (Tese revisada sob o rito do art. 1.036 do CPC/2015 - TEMA 600)

22) A causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas só pode ser aplicada se todos os requisitos, cumulativamente, estiverem presentes.

23) É inviável a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 quando há condenação simultânea do agente nos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, por evidenciar a sua dedicação a atividades criminosas ou a sua participação em organização criminosa.

25) Diante da ausência de parâmetros legais, é possível que a fração de redução da causa de diminuição de pena estabelecida no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 seja modulada em razão da qualidade e da quantidade de droga apreendida, além das demais circunstâncias do delito.

45) A natureza e a quantidade da droga não podem ser utilizadas simultaneamente para justificar o aumento da pena-base e para afastar a redução prevista no §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, sob pena de caracterizar bis in idem.

46) A utilização concomitante da quantidade de droga apreendida para elevar a pena-base e para afastar a incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, por demonstrar que o acusado se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa, não configura bis in idem, tratando-se de hipótese diversa da Repercussão Geral - TEMA 712/STF.

48) A utilização da reincidência como agravante genérica é circunstância que afasta a causa especial de diminuição da pena do crime de tráfico, e não caracteriza bis in idem.

Em todos esses enunciados, bem como no Tema Repetitivo n.º 600, o C. STJ admitiu indiretamente a viabilidade de incidência da circunstância privilegiadora do art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006, desde que observados cumulativamente os requisitos do dispositivo.

Também o STF firmou tese admitindo a aplicação do privilégio ao delito de tráfico, no julgamento do Tema n.º 712 de Repercussão Geral, no qual se firmou a seguinte tese: "As circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena".

Desse modo, nada há que se falar sobre eventual inconstitucionalidade da norma disposta no art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006.

No caso concreto, todavia, é incabível a aplicação da forma privilegiada do tráfico, eis que não observados cumulativamente todos os requisitos para sua aplicação.

Com efeito, o réu foi beneficiado com liberdade provisória em outro processo no dia 16.06.2021 e, menos de um mês depois, foi preso novamente pela prática, em tese, do mesmo delito que anteriormente: tráfico ilícito de entorpecentes (f. 25).

Tem-se, pois, que o réu tornou a delinquir pouco tempo depois de ter sido preso em flagrante, de modo que o tráfico não era praticado por ele de forma eventual e esporádica, mas rotineiramente – o que caracteriza sua dedicação ao crime.

Importante frisar, no ponto, que não é caso de aplicação da tese firmada no Tema n.º 1139 de Repercussão Geral do STJ, publicada no dia 18.08.2022, que assim aduz: "É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06".

Isso porque o privilégio vai afastado não em razão da ação penal a que responde o acusado, mas em virtude da dedicação do réu às atividades criminosas, caracterizada pela prática do mesmo delito – tráfico ilícito de entorpecentes – apenas pouco tempo depois de ter sido preso em flagrante pelo mesmo crime.

Inviável, nesses termos, a incidência da circunstância privilegiadora.

Nessa conjuntura, verifica-se que há subsunção da conduta do acusado ao tipo penal previsto no art. 33, caput, combinado com o art. 40, III, ambos da Lei n.º 11.343/06, uma vez que, com vontade e consciência, trazia consigo as porções de drogas indicadas na denúncia, sem autorização legal ou regulamentar, próximo a estabelecimento de ensino.

O fato é ilícito, pois reprovado pela lei penal, sendo que não foram alegadas ou comprovadas quaisquer causas justificantes.

O denunciado era maior de 18 anos de idade (imputável), tinha potencial consciência da ilicitude e, nas circunstâncias, era-lhe exigida conduta diversa. Presente, portanto, a culpabilidade.

Assim, passo a aplicar a pena, seguindo o método trifásico previsto no art. 68 do CP.

Inicialmente destaco que este Juízo, para a estipulação da pena base e o cálculo do aumento decorrente de eventual circunstância judicial – inclusive para a aferição de pena de multa cominada isolada ou cumulativamente –, leva em consideração o resultado do intervalo, abstratamente previsto pela lei, entre a pena mínima e a pena máxima, seguido da divisão por oito, conforme ensina Ricardo Augusto Schmitt: "O critério que vem sendo utilizado pelos Tribunais Superiores repousa numa situação prática e simples, que tem resultado a partir da obtenção do intervalo da pena prevista em abstrato ao tipo (máximo – mínimo), devendo, em seguida, ser encontrada sua oitava parte (1/8), ou seja, dividir o resultado obtido por 8 (oito), em vista de ser este o número de circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal. Com esse raciocínio, chegamos ao patamar exato de valoração de cada uma das circunstâncias judiciais (com absoluta proporcionalidade), o qual servirá de parâmetro para o julgador promover suas análises individuais" (Sentença Penal Condenatória. Teoria e Prática. Podivm. 6ª edição. Salvador/Bahia. 2011. p. 115/116).

A par disso, para a hipótese específica destes autos, incide o disposto no art. 42 da Lei n.º 11.343/06, que assim dispõe, in verbis: "O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente".

Neste cenário normativo, verifica-se que dois vetores do art. 42 da Lei de Drogas já estão inseridos expressamente nos parâmetros do art. 59 do CP – "personalidade e conduta social do agente". Outrossim, tem-se que "a natureza e a quantidade da

substância ou produto" podem ser analisadas no contexto das "circunstâncias" do delito, outro vetor do art. 59 do CP.

Assim, e pela necessidade da "preponderância" prevista no art. 42 da Lei n.º 11.343/06, alvitra-se valorar a personalidade e a conduta social do agente, assim como as circunstâncias do delito, com um peso mais significativo.

Como ressaltado anteriormente, costuma-se considerar o intervalo, abstratamente previsto pela lei, entre a pena mínima e a pena máxima, seguido da divisão por oito. Todavia, para preponderância aqui perseguida, prudente que a divisão seja feita por 11, uma vez que as circunstâncias do art. 42 da Lei de Drogas podem ser enquadradas em três vetores, tal como delineado acima – personalidade, conduta social e circunstâncias.

Fazendo isso, porém, deve-se dar aos vetores preponderantes o peso de 2/11, e aos demais, o de 1/11.

Assim, nos termos dos arts. 59 do CP e 42 da Lei n.º 11.343/06, à culpabilidade, aos antecedentes, aos motivos e às consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima (irrelevante em se tratando de crime vago como o tráfico de drogas), deve-se atribuir o peso de 1/11, constituindo 5/11 da pena-base; à conduta social e à personalidade do agente, assim como às circunstâncias, deve-se aplicar o peso de 2/11, configurando 6/11 da pena-base.

Desse modo, estará garantida a aplicação preponderante do art. 42 da Lei de Drogas, bem como assegurada, de forma mais escorreita e técnica, a individualização da pena.

Todavia, é necessário ressaltar que a fração indicada não deve ser aplicada de forma precisa, matematicamente. Trata-se, na verdade, de mero parâmetro para a fixação da reprimenda penal, de modo que as circunstâncias do caso concreto podem ensejar a exasperação maior ou menor da pena – ou maior ou menor compensação em caso de vetores favoráveis.

Feitas essas observações, à dosimetria da pena.

Pois bem, o acusado não ostenta maus antecedentes, que demandem a exasperação da pena, nos termos da súmula n.º 444 do STJ (f. 25).

Por outro lado, importante ressaltar que, em seu interrogatório, o denunciado afirmou ser usuário de drogas e consumi-las com frequência. Tal circunstância é desfavorável à conduta social do acusado, já que, além de traficar drogas, financia indiretamente esse delito equiparado a hediondo, crime esse que vem, cada vez mais, corroendo famílias e a própria sociedade.

Além disso, as circunstâncias do delito também são desfavoráveis. Com efeito, o denunciado estava na posse de entorpecentes de naturezas diversas, maconha, cocaína e crack, essa última de altíssimo poder destrutivo.

As demais circunstâncias do art. 59 do CP não são desfavoráveis ao réu, ou são normais ao tipo penal.

Nesse contexto, havendo duas circunstâncias judiciais preponderantes negativas (conduta social e circunstâncias do crime), fixo a pena base em 08 anos e 04 meses de reclusão – e 833 dias-multa.

Na segunda fase, incide a atenuante da confissão espontânea, na forma do art. 65, III, "d" do CP, tendo em vista que o réu confessou em juízo a prática do delito. Assim, reduzo a pena em 1/6, fixando-a, provisoriamente, em 06 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão – e 694 dias-multa.

Por fim, na última fase, incide a causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei n.º 11.343/06, uma vez que o crime foi praticado nas imediações de estabelecimento de ensino. No caso, o réu foi preso em flagrante às 16h55min de uma terça-feira, perto da CEMEB Tancredo de Almeida Neves – uma escola pública de ensino fundamental e que, portanto, possui alunos em fase de pré-adolescência. Essas circunstâncias aumentam a culpabilidade do acusado e impõem o aumento da pena em fração superior à mínima legal, em 1/3.

Assim, exaspero a reprimenda em 1/3, fixando-a, agora definitivamente, em 09 (nove) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão – e 925 (novecentos e vinte e cinco) dias-multa.

O valor do dia-multa fica estabelecido em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente no país na data dos fatos, considerada a presumida precariedade da situação

financeira do denunciado, valor a ser atualizado quando do efetivo pagamento. De acordo com o art. 2.º, § 1.º, da Lei n.º 8.072/90, fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade.

Ressalte-se, nesse passo, que é inconstitucional a Lei n.º 12.736/2012, que determina a consideração da detração penal para fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade.

Isso porque viola o princípio constitucional da isonomia, já que, aplicando-se a referida lei, haverá situações em que pessoas condenadas exatamente às mesmas penas e pelos mesmos crimes terão tratamento totalmente diferente em situações iguais. Assim, o sentenciado condenado à pena privativa de liberdade, e que tenha sido preso provisoriamente, terá abatido o período pelo próprio Juiz da Condenação para fins de progressão, podendo ser diretamente promovido de regime sem a observância do seu comportamento carcerário (requisito subjetivo). Por outro lado, o condenado que não tenha cumprido prisão provisória deverá obter a progressão com o preenchimento dos requisitos do artigo 112 da Lei das Execuções Penais, a serem analisados pelo Juiz das Execuções Criminais. Há, portanto, dois pesos e duas medidas, ou seja, pessoas sendo tratadas de forma totalmente diferente em situações iguais, violando, assim, o princípio constitucional da isonomia (CF, art. 5.º, caput).

Dessa forma, deixo de aplicar a Lei n.º 12.736/2012.

A detração deverá ser observada pelo juízo da execução, não havendo qualquer prejuízo ao acusado.

Mantenho a custódia cautelar do denunciado, pois não modificadas as situações que determinaram a sua necessidade. Recomendo o réu na prisão onde se encontra.

Incabível a substituição ou a suspensão condicional da pena privativa de liberdade (CP, arts. 44, inciso I, e 77, caput).

Em razão do exposto, julgo procedente a pretensão acusatória para condenar o réu JEAN LEANDRO MOREIRA DA SILVA, já qualificado, ao cumprimento da pena de 09 (nove) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão – e ao pagamento de 925 (novecentos e vinte e cinco) dias-multa, pela infração ao art. 33, caput, combinado com o art. 40, III, ambos da Lei n.º 11.343/06, a ser cumprida em regime inicial fechado.

O valor do dia-multa fica estabelecido em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo federal vigente no país na data dos fatos, valor a ser atualizado quando do efetivo pagamento.

Expeça-se a guia de execução provisória.

Deixo de fixar a verba mínima indenizatória do art. 387, IV, do CPP, pois se trata de crime vago.

Determino a perda dos bens apreendidos a favor da União, nos termos dos arts. 91, II, do CP e 63, I, da Lei n.º 11.343/2006.

Custas pelo réu (CPP, art. 804), no valor de 100 UFESPs (Lei n.º 11.608/2003, art. 4.º, § 9.º, “a”), cuja exigibilidade fica suspensa em razão de estar litigando sob o pálio da assistência judiciária gratuita, que agora lhe fica deferida, anotando-se.

Após o trânsito em julgado:

- (a) lance-se o nome do réu no rol dos culpados ou instituto equivalente;
- (b) expeça-se a guia de execução definitiva;
- (c) oficie-se ao E. Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo, comunicando a condenação do réu, com sua devida identificação, acompanhada do inteiro teor da presente sentença, para cumprimento do quanto disposto pelo art. 71, § 2º, do Código Eleitoral combinado com o art. 15, inciso III, da Constituição Federal;
- (d) oficie-se ao Senad, nos termos do art. 63, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006; e
- (e) arquivem-se os autos com as anotações e comunicações necessárias.

P.I.C.

Itapevi, 21 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA